刑法12 筆記：不能未遂考題演練

> 來源：刑法12 課程字幕 00:00:00 ~ 00:22:00

🕮 法條原文速查

> **§26**（不能未遂）
> 行為不能發生犯罪之結果，又無危險者，**減輕或免除其刑**。

> **§225**（趁機性交罪）
> I 對於男女利用其精神、身體障礙、心智缺陷或其他相類之情形，不能或不知抗拒而為性交者，處三年以上十年以下有期徒刑。
> II 對於男女利用其精神、身體障礙、心智缺陷或其他相類之情形，不能或不知抗拒而為猥褻之行為者，處六月以上五年以下有期徒刑。

> **§13**（故意）
> I 行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為故意。
> II 行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，以故意論。

> **§29**（教唆犯）
> I 教唆他人使之實行犯罪行為者，為教唆犯。
> II 教唆犯之處罰，依其所教唆之罪處罰之。

> **§30**（幫助犯）
> I 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
> II 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

📋 釋字/實務見解原文速查

> 本筆記以學說案例解析為主，無特定釋字/實務見解。

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「§26 不能未遂的兩大要件」	①行為**不能發生犯罪結果**（客觀）；②又**無危險**（行為人主觀有重大無知）
「被害人已死亡，行為人以為尚活著而性交，成立何罪？」	§225 趁機性交罪之**不能未遂**（客體不能＝被害人已死亡，不存在活人客體）
「正犯成立不能未遂，共犯如何論處？」	視**不能未遂體系定位**：三階外→正犯仍有罪，共犯可從屬；構成要件不該當→正犯不該當，限制從屬下共犯有問題
「花生牛奶案：共犯提供過敏資訊，但正犯下毒不相干？」	**正犯自己不能未遂**（手段不能），但共犯的「幫助」本身是否構成不能未遂，須**獨立判斷**
「隔離犯何時著手？（如寄毒包裹）」	三說：①**寄出時**（行為人角度）；②**離開行為人掌控時**（通說）；③**到達被害人可支配範圍時**
「客體不能 vs 手段不能的區分」	**客體不能**＝犯罪對象不存在（如屍體非活人）；**手段不能**＝使用的方法根本不可能產生結果（如糖水當毒藥）

正文

一、不能未遂要件複習

```
不能未遂（§26）
│
├── 要件一：行為不能發生犯罪結果（客觀）
│     ├── 客體不能（犯罪對象不存在）
│     │     └── 例：對屍體開槍
│     └── 手段不能（方法根本無效）
│           └── 例：用糖水當毒藥
│
├── 要件二：又無危險（主觀重大無知）
│     └── 行為人對於手段或客體有重大認知錯誤
│
└── 法律效果：減輕或免除其刑
```

兩大要件的操作

1. **客觀面——不能發生犯罪結果**：從事後客觀角度看，行為根本不可能達到既遂
2. **主觀面——行為人有重大無知**：行為人對於手段或客體有嚴重的認識錯誤，一般人不會這樣誤判

> ⚠ 兩要件須同時成立，才是 §26 不能未遂。若客觀上不能既遂但行為人無重大無知，仍成立**普通未遂**。

二、案例：趁機性交罪的客體不能

事實

1. 被害人已因故死亡
2. 行為人不知被害人已死，以為被害人處於不能抗拒之狀態
3. 行為人對被害人為性交行為

分析

（一）§225 趁機性交罪之構成要件

- 客觀：須有「利用不能或不知抗拒」之事實狀態，且對象須為**活人**
- 被害人已死亡 → 根本不是 §225 保護的活人客體 → **客體不能**

（二）不能未遂（§26）的檢驗

- 要件一（不能發生犯罪結果）：✓ 被害人已死，性交行為不可能侵害活人的性自主法益
- 要件二（又無危險 / 重大無知）：✓ 行為人誤以為死者為活人，此認知錯誤缺乏合理基礎

（三）結論

- 成立 **§225 趁機性交罪之不能未遂**，依 §26 減輕或免除其刑

三、案例：花生牛奶案（正犯不能未遂與共犯的關係）

> 老師評為「不能未遂最難的一題」

事實

1. 甲知道 A 對花生嚴重過敏，告訴乙此資訊
2. 乙想殺 A，但乙**沒有用花生**，而是用了**另一種完全無害的物質**下毒
3. 乙的下毒方式根本不可能致 A 於死（手段不能）

分析

（一）正犯乙的罪責

- 乙主觀有殺人故意，客觀上使用了根本不可能致死的手段 → **手段不能**
- 若乙對於手段有重大無知 → 成立殺人罪之**不能未遂**（§26）
- 若乙對手段之認知錯誤不算重大無知 → 成立**普通未遂**

（二）共犯甲的罪責——爭議核心

- 甲提供花生過敏資訊（教唆 or 幫助），但乙根本沒有利用這個資訊

- **問題**：正犯自己成立不能未遂時，共犯如何處理？

不能未遂的體系定位	對共犯的影響
三階層以外（獨立量刑事由）	正犯的行為仍該當＋違法，共犯可以從屬成立
構成要件不該當	正犯不該當，限制從屬下共犯無從依附

（三）共犯自己的不能未遂

- 即使正犯的行為讓共犯可以從屬，共犯**自身也可能構成不能未遂**
- 甲提供的資訊（花生過敏）根本沒被正犯使用 → 甲的幫助行為**不能發生促進犯罪的結果**
- 若甲對此有重大無知 → **幫助犯的不能未遂**

四、隔離犯著手問題

什麼是隔離犯？

- 行為人的行為與結果發生之間有**時間與空間的間隔**
- 典型案例：寄送毒包裹、設置定時炸彈、遠端投毒

著手時點三說

```
隔離犯著手時點
│
├── 說一：寄出時（行為人完成自己該做的行為時）
│     └── 以行為人角度判斷
│
├── 說二：離開行為人掌控時（通說）
│     └── 例：包裹交給郵局後，行為人無法取回
│     └── 重點：行為人對因果歷程已失去控制
│
└── 說三：到達被害人可支配範圍時
      └── 例：包裹送到被害人家門口
      └── 以被害人角度判斷
```

學說	著手時點	理由
說一	行為人寄出時	行為人已完成行為
說二（通說）	離開行為人掌控時	行為人對因果流程失去控制
說三	到達被害人範圍	法益面臨直接危險

> 隔離犯著手時點的選擇，會影響到後續中止未遂的判斷：若尚未著手，討論的是**預備階段中止**而非中止未遂。

關鍵法條速查表

法條	內容	與本主題關聯
§26	不能未遂：減輕或免除其刑	本筆記核心
§225	趁機性交罪	客體不能案例
§13	故意定義（直接故意＋間接故意）	行為人主觀意思判斷
§29	教唆犯	共犯從屬性討論
§30	幫助犯	花生牛奶案共犯分析